

Derechos Intelectuales: Protección del software.

Derechos Intelectuales.

1.-Concepto. Su naturaleza jurídica.

Se conocen como derechos intelectuales a todas las relaciones que se establecen entre los frutos de un trabajo intelectual, ya sean patentes de invención, creaciones artísticas o denominaciones comerciales, y su autor. Si bien normalmente se utiliza el término “propiedad” para denominar a este conjunto de derechos, ello no quiere decir que los mismos deban englobarse en los llamados derechos reales.

Al analizar los derechos subjetivos, habíamos dividido a los mismos en dos grandes grupos: personales y reales. Freitas, en su libro *“La consolidación de las leyes civiles”*, es el autor de dicha división, la cual, sostiene, da orden y engloba la universalidad de derechos posibles.

Velez Sarsfield fue influido de manera directa por el pensamiento de este autor brasileño, circunstancia que es reconocida por el propio autor del código en la nota de elevación del proyecto al congreso nacional para su tratamiento. Esta influencia no se limita a simplemente a la copia de los artículos, sino que incluso la estructura del código civil mismo refleja esta concepción: el cuerpo legal está dividido en cuatro libros: los dos primeros tratan sobre los derechos personales (relaciones de familia y relaciones civiles), en el tercero, los derechos reales y en el cuarto, las disposiciones comunes a ambas clases de derechos.

Tradicionalmente el derecho real se lo ha definido como una relación jurídica que se establece directamente entre el titular del

derecho y la cosa que su objeto. Así, por ejemplo, el dominio sobre un automotor, es una relación establecida entre el titular del mismo y el vehículo en cuestión, con prescindencia de todo otro tercero. Atento esta ausencia de sujetos pasivos determinados, el derecho real es un derecho absoluto, en el sentido de ser oponible a cualquier persona, haya tenido participación en el negocio jurídico que constituyó el derecho real o no

En sentido contrario, los derechos personales vinculan a dos o más personas determinadas o determinables, de forma tal que una de ellas (el acreedor) tiene la potestad de exigir a la otra (el deudor), el cumplimiento de una prestación determinada. Por tanto, la relación personal se establece entre estas dos partes, siendo los terceros ajenos a la misma, sin que por tanto pueda obligarlos a soportar sus efectos. Por ello es que se dice que los derechos personales generan una efectos relativos, limitándose a las partes y siendo inoponibles a los terceros.

Los derechos intelectuales, en realidad, no participan de esta gran división establecida por Freitas y Velez. En primer lugar, a diferencia de los derechos reales, el derechos intelectual no recae sobre un objeto material. Que un novelista mantenga sus derechos de autor sobre una obra, no significa que el mismo establezca una relación de dominio respecto a todos los libros impresos: Estos son propiedad de las personas que los adquirieron, limitándose el autor a recibir un beneficio económico por la explotación del texto. Sin embargo y esto es una diferencia fundamental con un derecho personal, este derecho a percibir las regalías debe ser respetado por cualquier tercero, siendo por tanto absoluto.

En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que el derecho de autor mantiene un segundo aspecto de carácter extrapatrimonial, que lo aleja todavía más de los derechos subjetivos tradicionales. Toda

actividad intelectual, en particular las relacionadas con el arte, tienen por fin, a falta de una expresión mejor, la gloria de su autor. Esta idea es recogida por la legislación de derechos de autor mediante los denominados derechos morales. Estos consisten, básicamente, en la obligación de reconocimiento de la autoría de la obra, así como la posibilidad de determinar el destino final de la misma.

A diferencia de los beneficios pecuniarios derivados del trabajo intelectual, los derechos morales no son transmisibles y permanecen con el autor. Así, y siguiendo con el ejemplo anterior, si el novelista hubiera vendido los derechos de explotación de la obra, no percibiría regalías, las cuales irían a manos del nuevo titular. Sin embargo, ello no es obstáculo para que tenga derecho a ser reconocido como autor de la obra y, en caso de creerlo conveniente, modificar total o parcialmente el texto o incluso solicitar el retiro y destrucción de los ejemplares, esto último, por supuesto previa indemnización de los perjuicios producidos a los terceros.

Como conclusión, podemos expresar los siguientes enunciados:

1.- Los derechos intelectuales son una clase aparte de los derechos reales y personales.

2.- El derecho de autor tiene un doble aspecto: Uno patrimonial, referido a los derechos de explotación de la creación intelectual, y otro de naturaleza extrapatrimonial, referido a los derechos morales derivados de la obra.

3.- Mientras que los derechos patrimoniales son susceptibles de transmisión, los derechos morales permanecen con el autor de la obra.

1.2.- Regulación de los derechos intelectuales en nuestro ordenamiento:

El sistema jurídico argentino regula los derechos intelectuales mediante tres leyes fundamentales, las cuales son:

- 1.- Ley 11.723. de propiedad intelectual.**
- 2.- Ley 24.481 de patentes de invención**
- 3.- Ley 22.362 de marcas y designaciones.**

A los efectos de la protección de los derechos de autor del software, la ley 24.481 carece de aplicación, por lo que no será analizada.

Si bien a primera vista pareciera una contradicción la regulación de una actividad como la informática mediante la utilización de institutos pensados para protección del autor de una obra artística, ello obedece a la necesidad de concordar la legislación argentina con la del resto del mundo. En este aspecto, la adopción del régimen de derechos de autor para la protección del software, es una solución extraída del common law. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que su equivalente en el derecho anglosajón, el copyright, presenta algunas diferencias notorias con el derecho autoral, las cuales hacen que muchas veces las regulaciones aparezcan como forzadas o poco claras.

2.- Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Derivados de una obra científica, artística o literaria.

2.1- Ambito e aplicación: El art. 1 del al el 11.723 sostiene que *“A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto, las compilaciones de datos y otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, drámatico-musicales, las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujos, pintura, escultura, arquitectura,*

modelos y obras de arte o ciencia aplicada al comercio o a la industria, los impresos, planos y mapas, los plásticos, fotografías, grabados y discos fonográficos, en fin, toda producción científica literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción”

“La protección de los derechos de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”

La enumeración contenida en la norma no es taxativa y, por otro lado, la amplitud final del artículo ha permitido incluir las innovaciones tecnológicas, lo que en líneas generales ha mantenido a la ley actualizada. Esto, tal como veremos más adelante, no ha sido el caso con el software, lo que ha motivado una reforma en el art. 1, a los efectos de incluirlo expresamente.

El derecho de autor, tal como su nombre indica, necesita que la idea, como proceso eminentemente intelectual, se exteriorice en una producción, es decir un elemento corpóreo que incorpore esos fundamentos **teóricos en un bien determinado y protegible**. Retomando el ejemplo anterior, la ley protege la novela como ente, pero no su idea, tema o argumento: Lo tutelable es el producto en tanto existe en la realidad y no los meros proyectos o promesas.

Asimismo es necesario que la obra tenga un grado de originalidad. En este sentido, una originalidad absoluta no es concebible ni requerida, habida cuenta que todo bien cultural es expresión de la sociedad que le da cabida. Este es el fundamento principal de la limitación a los derechos de explotación que veremos más adelante.

2.2.- Tutela de los derechos. Inscripción registral:

Tal como sostuvimos en los paragrafos referidos el autor de la obra tiene derecho a la explotación de la misma, como así disponer la enajenación de los derechos económicos derivados, lo cuales son válidos por el términos otorgados por la ley para su protección.

En todos los casos, el autor siempre conserva los derechos morales sobre la obra, por lo que mas allá de la enajenación, mantiene la prerrogativa a que se lo reconozca como autor de la obra y tiene facultades de disposición sobre la misma.

A los efectos de que la protección se haga efectiva, es necesario la inscripción de la obra en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual. La ley regla de manera minuciosa el procedimiento mediante los art. 57 a 63.

A los efectos de iniciar el trámite se deberán depositar tres ejemplares completos de toda la obra publicada. Este regla encuentra su excepción en los casos de que se trate de una edición de lujo o de menos de diez ejemplares (como, por ejemplo, un software no enlatado). En tales casos, basta con depositar un único ejemplar.

Los arts. 58 a 60 fijan el procedimiento ordenando la publicación en el boletín oficial de los datos que identifiquen la obra (título de la misma, autor, clase de obra, etc). **Esta publicidad se realiza a los efectos de poder recibir las oposiciones de terceros que consideran tener derechos sobre la obra**, actividad que se realizará durante el mes posterior a la publicación.

En caso que hubiera oposiciones, se las comunicará al autor por el término de cinco días para que conteste. Vencido dicho plazo es el director del registro quien decidirá sobre la inscripción de la obra, resolución que es apelable por el término de diez días.

El art. 63, por último, define los efectos que tendrá la inscripción las cuales serán declarativos. En función de ello, y en los casos que no

exista inscripción, los derechos de los autores se suspenden, recuperándose al momento de la inscripción.

2.3 .- Titulares del derecho. Plazos. Autores extranjeros:

Según la enumeración del art. 4 de la ley, los titulares del derecho son el titular del derechos son

1.- El autor de la obra

2.- Sus herederos

3.- Los que con permiso del autor, la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la sobre una nueva obra intelectual resultante. Esto no quiere decir que, por ejemplo, los traductores o adaptadores obtengan de derechos respecto a la obra original, sino solamente a la traducción o adaptación realizada, la cual se considera una nueva obra protegible.

El derecho de autor es vitalicio y en los casos de obras en colaboración, se extiende hasta la muerte del último coautor. **Según el art. 5 de la ley extiende el derecho de los sucesores del autor por el término de setenta años** desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. En caso que el autor no tuviere herederos, los derechos derivados de la obra pasan al estado, quien puede explotarlos como si fuera un particular.

Una vez vencido dicho plazo, la obra entra en lo que se conoce como dominio público, quedando sin efecto los derechos patrimoniales derivados de la misma y permitiéndose su utilización a título gratuito por el resto de la población.

Con respecto a los autores extranjeros, los mismos se encuentran protegidos por la 11.723, siempre que acrediten el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley. **El convención de ginebra, ratificada en el país, dispone que la exigencia de la registración, requisito fundamental para la**

protección de la ley se encontrará cumplida con la incorporación del símbolo (c) junto con el nombre y el año de la primera publicación.

Con respecto al lapso de protección para los autores extranjeros, la regla es que la protección otorgada en el país no se extenderá mas allá de la otorgada en el país de origen ni tampoco superará los establecidos en la 11.723. De esta manera, los derechos patrimoniales sobre las obras extranjeras se extenderán hasta el término menor establecido entre la legislación de origen o la argentina.

2.4.- Protección civil y penal contra la violación de la propiedad intelectual.

La tutela del derecho de autor se completa en la ley con la configuración de tipos penales específicos, la posibilidad de la denuncia publica ante el registro y la substanciación de un procedimiento civil particular.

En el aspecto penal, el art. 71 impone al que defraude los derechos de propiedad intelectual de otro, la pena establecida en el art. 172 del Código penal, el **cual impone un mínimo de seis meses y un máximo de seis años de prisión al autor penalmente responsable.**

Asimismo el art. 72 fija algunos tipos particulares como casos específicos de defraudación, a los cuales se debe aplicar la pena del 172 del Cod. penal.

Las acciones penadas son las siguientes:

- 1.- **El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor**
- 2.- **El que falsifique la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el título del editor autorizado.**

3.- El que reproduzca o venda una obra, modificando el nombre del autor, el título o el texto dolosamente.

4.- El que edite o reproduzca mayor número de ejemplares que los convenidos con el autor.

Todos estos delitos pueden ser denunciados por cualquier particular o incluso pueden ser iniciados de oficio por la autoridad pública, circunstancia que, en la provincia, es obligatoria en los casos en que un agente de la administración pública tenga noticia de la comisión de los delitos. Asimismo, y atento la pena máxima impuesta, **no gozan del beneficio de la excarcelación.**

El procedimiento civil presenta algunas particularidades: en primer lugar constituye un procedimiento abreviado. La ley hace referencia a la aplicación de las reglas de excepciones dilatorias. Atento la modificación del código de procedimiento serán de aplicación las reglas de las excepciones previas, que son la figura procesal que suplantó a las anteriores.

La novedad principal respecto es la posibilidad de formación de un jurado técnico, el cual podrá ser presidido por el decano de la facultad de Filosofía y Letras, Exactas, del Museo Nacional de Bellas Artes o el Conservatorio Musical. **Este jurado de notables cumple las funciones de la prueba pericial, debiendo declarar si existe o no lesión a la propiedad intelectual.** Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el dictamen no es vinculante.

De la misma forma, esta vez restringido a las obras que se encuentran en el dominio público, cualquier particular puede denunciar ante el registro nacional de propiedad intelectual la modificación o cercenamiento de la obra. En tales casos el registro debe constituir un jurado expertos a los efectos de dictaminar sobre la veracidad de la denuncia. A diferencia del proceso civil, en este caso el

dictamen es vinculante y puede imponer multas y/o secuestrar la obra objeto de reclamo.

3.- Marcas y Denominaciones comerciales

3.1.- Concepto:

Un mercado solo puede operar eficientemente cuando los consumidores realizan sus decisiones luego de haber recibido la información apropiada. Para ello es necesario que el público pueda diferenciar entre un producto y otro. En todo mercado en el que existe más de un productor de un bien o servicio, es necesario que exista signos exteriores en los mismos, de forma tal que los consumidores puedan diferenciar los mismos claramente. Es a partir de la existencia e interacción de estos signos, que se busca evitar toda confusión entre los posibles productos.

Por tanto podemos decir que **la marca es el signo característico y distintivo con que el productor de un bien o prestador de un servicio distingue sus productos o servicios**

Hoy en día, y en función de la extensión de la economía de masas, las marcas comerciales superan su función primaria de identificar un producto para constituir un bien económicamente valioso. La publicidad y el marketing generan una asociación entre una determinada marca y un grupo de valores o aspiraciones sociales que permiten una mejor comercialización, al establecen una identificación entre el usuario, el producto y los valores presentados. Así, por ejemplo, la automotriz Volvo invierte grandes sumas de dinero los efectos de ser asociada con los valores de confiabilidad y seguridad. Esto permite una mejor comercialización del producto, lo que redundará en mayores márgenes de ganancia.

Si bien la ley de propiedad intelectual es consagra la protección de software como obra, **nada ordena respecto a los signos distintivos que el mismo, como producto comercial, emplee para distinguirse de**

sus semejantes. Por ello, y a los efectos de su protección, es necesario el estudio de la legislación de marcas.

3.2.- Clasificaciones:

La clasificación de las marcas puede hacerse mediante los más diversos criterios. Entre los principales podemos mencionar:

1.- Marcas de productos y marcas de servicios: Las marcas tradicionalmente han distinguido productos. Recién con en el año 1967 con la firma del convenio de París, se introdujeron las marcas de servicios. Hoy día la ley 22.362 adopta la clasificación internacional determinando que las clases 1 a 34 corresponden a productos y la 35 a 42 a servicios.

2.- Marcas registradas o de hecho: Dependerá si las mismas se encuentran inscriptas o no. En principio, y salvo excepciones, solamente las registradas tienen protección legal.

3.- Marcas originales y de defensa: Las marcas de defensa son aquellas inscriptas en categorías diferentes a la del producto y servicio que representa. Su función es evitar que la marca original se diluya, mediante la proliferación de productos de igual nombre en otras rubros. Veremos el tema con más detalle al analizar la cuestión de las categorías.

3.3.- Régimen Aplicable:

3.3.1. El concepto de marca: El art. 1 plantea un criterio amplio en lo referente a que es lo que puede considerarse marca. Entre otras cosas, enumera que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o mas palabras, los dibujos , emblemas, monogramas, combinaciones de alfanuméricas, de colores, formas

geométricas o cualquier otro signo con capacidad distintiva. La enunciación no es taxativa, atento lo observado por la última parte del art.

Los art. 2 y 3, en sentido contrario, limitan cuáles son las marcas posibles de registrar. Así, el art. 2 no permite considerar marca a la características habituales del producto como su nombre genérico, las cualidades del mismo, la forma, su color o cualquier característica que haya pasado al uso general antes de la inscripción.

En el mismo sentido, el art. 3 no podrán ser marcas las denominaciones de origen, las expresiones que puedan dar lugar a error respecto a las características del objeto o aquellas reservadas a la nación, provincias estados extranjeros, o cualquier otra persona de derecho público.

3.3.2. Adquisición del derecho. Régimen de inscripción:

El art. 4 de la ley establece la necesidad de inscripción registral de las marcas y otorga a las mismas carácter constitutivo, al ordenar que la propiedad de una marca y su exclusividad se otorgan con la inscripción. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este principio no es absoluto, ya que muchas veces la jurisprudencia ha protegido marcas no inscriptas, aún las extranjeras, en los casos que las mismas sean notorias.

Otra característica particular de la regulación marcaría es que la inscripción se realiza en distintas categorías preestablecidas, de forma tal que una misma marca (normalmente en los casos en que se trate de palabras o expresiones alfanuméricas) puede aludir a productos o servicios diferentes. Tal sería el caso, por ejemplo, de una panificadora llamada Sublime y una marca de cal del mismo nombre. En ambos casos, la inscripción podría realizarse, ya que las marcas refieren a productos sin ningún tipo de relación.

El art. 10 y siguientes legisla lo relativo al trámite de registro de las marcas, estableciendo que se deberá presentar una solicitud por cada clase que se solicite y constituir un domicilio en la Capital Federal, en el cual se realizarán todas las notificaciones del procedimiento de inscripción.

Presentada la solicitud y realizado un primer examen de legalidad por la autoridad de aplicación, se realiza una publicación por un día en un boletín especial denominado "Boletín de Marcas". Una vez finalizada la misma, la dirección nacional de propiedad industrial en su carácter de autoridad de aplicación de la ley tiene treinta días para realizar un estudio de los antecedentes del pedido. En el mismo lapso, los particulares con un interés legítimo, podrán oponerse al otorgamiento de la marca, mediante una presentación por escrito, el cual de estar fundamentada.

Habiendo mediado oposición o no, y en el primer caso, cualquiera fuera el resultado, la dirección podrá negar la inscripción si considera que no se reúnen los requisitos de la ley. En tales casos, tal resolución puede ser impugnada por demanda ordinaria contra la autoridad de aplicación, la cual deberá ser interpuesta dentro de los treinta días de notificado el acto administrativo, entendiendo en la causa la justicia federal civil y comercial.

3.3.3. Lapso de duración de la marca. Las marcas de defensa.

El término de duración de una marca comercial es de 10 años, prorrogable indefinidamente por el mismo lapso a instancias del titular de la misma.

El único requisito que la ley obliga a cumplir para la renovación es la utilización de la marca por lo menos en una de las categorías inscriptas en el término anterior. De manera que es posible inscribir la

marca en categorías que en realidad jamás se tuvo la intención de usar. Estas se conocen como marcas de defensa.

La razón fundamental para tomarse esta molestia es evitar el fenómeno que se conoce como disolución de marca. Tal como se dijo en la introducción de este capítulo, las marcas comerciales constituyen un valor en si mismo toda vez que se relacionan con ciertos valores impulsados desde el marketing. Pero esta relación debe ser mantenida, evitando que la misma se pierda mediante la introducción de productos que no cumplan las expectativas que los consumidores tienen la marca. El fenómeno de la disolución, entonces, permite que terceros, ajenos a la productor original, se sirvan del valor de la designación comercial, utilizándola en objetos o servicios que no tienen directa relación con el original. De esta forma no solo consiguen un beneficio sin causa sino que diluyen la marca original, la cual ahora se expande en categorías no previstas ni queridas por fabricante original. Para evitar ello, se utilizan las llamadas marcas de defensa, las cuales impiden el registro por parte de terceros y limitan la dilución en los rubros que normalmente podrían beneficiarse de la confusión.

3.3.4.- Protección civil y penal:

Al igual que la ley de propiedad intelectual, el derecho de marcas organiza tipos penales y reglamenta una acción civil a los efectos de su defensa.

En este sentido el art. 31 define una serie de tipos penales específicos, los cuales mantienen una pena de tres meses a dos años de prisión. Las conductas punibles abarcan a quien falsifique una marca registrada, quien la utilice sin autorización o quien la comercialice. Estos delitos son de acción pública y tramitan ante la justicia federal.

La acción civil seguirá el trámite del juicio ordinario ante la justicia federal en lo civil y comercial y perseguirá la cesación en el uso no autorizado de la marca

Tanto el querellante en la causa penal como el demandante en la civil pueden solicitar se ordene el secuestro de las mercadería que lleven la marca en infracción. Asimismo el régimen de medidas precautorias es notoriamente más accesible que el regulado por la ley de propiedad intelectual. Esta característica lo hace particularmente útil en la defensa jurídica del software, utilizando la defensa de la marca comercial para solicitar el secuestro de las copias ilegales.

4.- Defensa Jurídica del Software

Tal como vimos al analizar el art. 1 de la ley 11.723, en la actualidad los obras del software se encuentran protegidas por la ley. Sin embargo, esta modificación es relativamente moderna y es el resultado de una discusión referente a la necesidad o no de legislar el tema y aun en caso afirmativo, cuál era la mejor forma de hacerlo.

La doctrina se dividía básicamente entre quienes sostenía que la enunciación del art. 1 era lo suficientemente amplia como para incorporar a los programas de computación y aquellos que por el contrario entendían que era necesaria una recepción legislativa expresa, ya sea mediante la reforma de la ley de propiedad intelectual, sea mediante la sanción de una ley específica al efecto.

Hasta el año 1997, la primera de las visiones prevaleció. El decreto del poder ejecutivo nacional 165/94 otorgaba el carácter de obra tanto al software como a los bancos de datos, en la concepción que dicha reglamentación permitía incluir a dichas creaciones dentro de la protección tanto penal como civil otorgada por la ley 11723.

Esta concepción entró en crisis en el año 1997 mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Pellicori, Oscar y otros s/Denuncia por defraudación” o como popularmente se lo conoció, el caso Autodesk. En dicha sentencia, la corte entendió que la venta de programas sin licencia, lo que vulgarmente se conoce como piratería, no constituía un delito dentro del ordenamiento argentino. El fundamento del fallo establecía que la reglamentación de una ley, cosa que era el decreto 165/94, no podía ampliar los bienes protegidos por una ley, toda vez que ello implicaba una modificación a la misma. Por tanto, y por lo menos desde el punto de vista penal, la conducta no era punible, ya que no había una ley que estableciera la misma como una actividad ilícita.

Este fallo, que generó una amplia cobertura en los medios masivos de comunicación, determinó la sanción de la modificación de la ley 11723 a los efectos de incorporar en su art. 1 al software y los bancos de datos.

La incorporación del software y las bases a la ley de propiedad intelectual, tiene asidero en los antecedentes en el derecho internacional y en la doctrina y legislación comparada. En este sentido, la república argentina ya había firmado el acuerdo TRIPS, ratificado por ley 24245 disponiendo que *“los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias según el convenio de Berna.”*. En este sentido, la incorporación del software a la ley de derechos de autor, guarda directa relación con la legislación del *Common Law* inglesa y americana. En estos ordenamientos el *copyright*, funciona como un equivalente a la expresión derechos de autor, aunque dicha similitud no es total.

En función de ello, la solución adoptada, fue criticada por aquellos autores que entendían hubiera sido conveniente la sanción de una ley específica. El problema fundamental en referencia a la inclusión lisa y llana a la legislación de los derechos de autor, es que el instituto fue concebido tradicionalmente en el derecho continental como una mecanismo de defensa de los derechos de las creaciones científicas y particularmente artísticas: Así, la existencia de derechos e incluso el lapso de protección de los derechos durante setenta años aparece como exagerado o por lo menos de dudosa aplicación directa a una obra como el software, que tiene más puntos de contacto con un producto comercial que con una expresión de la individualidad de su autor.

En otro sentido, la protección procesal obtenida mediante la ley de derechos de autor aparece muchas veces como deficiente, siendo conveniente el registro de la marca a los efectos de lograr el secuestro

de las copias ilegales o incluso las máquinas donde estas se encuentran contenidas.

4.2.- Breves nociones en referencia a las licencias de uso, cesión de código fuente y software libre.

Por último analizaremos algunos de los mecanismos contractuales más comunes referidos a la cesión dl derecho de uso de un programa y las diferencias fundamentales referidas al software libre y propietario.

Un contrato de licencia de uso es aquel por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual sobre un programa, transfiere a la otra parte, conocida como licenciataria, el uso y goce del programa. Pero el titular de la licencia conserva la titularidad del programa y limita en forma clara cuáles son las actividades que el licenciataria pueda realizar. En este sentido, esta prohibida la reproducción total o parcial del programa, salvo la excepción derivada del derecho de realizar una copia de seguridad del mismo.

Es usual, asimismo, que solo el código objeto o programa compilado sea entregado al licenciataria, al cual se le prohíbe realizar retroingeniería a los efectos de lograr un nuevo código fuente. Como contrapartida, el licenciante normalmente asume la obligación de realizar el mantenimiento o actualización de los programas licenciados, durante la duración de la relación contractual.

Sin embargo, puede haber casos en que sea necesario el acceso al código fuente. Tal es el caso que la empresa licenciataria tenga interés en realizar un desarrollo propio a partir del programa adquirido o en cuando, en función de consideraciones económicas decida prefera hacerse cargo del mantenimiento y/o actualización del

software. En estos casos, es normal realizar una cesión del código fuente.

Un contrato de cesión de código fuente entrega no solo el uso y goce de la software desarrollado sino, y tal como su nombre lo indica, el código originalmente escrito por el programador en lenguaje de alto nivel, de forma tal que otorga al cesionario del mismo la capacidad de realizar modificaciones y compilarlas, generando un nuevo código objeto. Puede decirse que en tales casos el autor del software pierde el control sobre el destino del mismo, circunstancia que suele verse reforzada por cláusulas de exclusividad de explotación en beneficio del cesionario.

En la práctica, la elección de una u otra forma contractual depende fundamentalmente de la capacidad negocial de las partes. Usualmente, el desarrollador del software tiende a la utilización de la licencia de uso, de forma tal de asegurarse los beneficios derivados del contrato de mantenimiento, así como mantener la exclusividad de la explotación del programa. Excepcionalmente podría optar por la entrega del código fuente en los casos de software a medida y cuyas soluciones no podrían aplicarse a nuevos emprendimientos. Sus co-contratantes, en cambio, y sobre todo en el caso que cuenten con un departamento informático, optan por la entrega del código fuente, evitando el costo derivado del contrato de mantenimiento y los riesgos de una posible desaparición del proveedor informático y con el la posibilidad de actualización del software.

Software libre: Popularmente se ha entendido que el software libre se caracteriza por una absoluta libertad respecto a su utilización, configurándose como una respuesta a la idea de propiedad y explotación comercial de los modelos tradicionales de comercialización conocidos como software propietario.

En realidad, el software libre no carece de limitaciones. Cada persona que utiliza un software sometido a este régimen acepta una licencia general de uso que impone derechos y obligaciones. A diferencia de una obra de dominio público, la cual puede ser utilizada con fines comerciales, el software libre impide al usuario la comercialización de los desarrollos realizados bajo el sistema. La licencia general de uso prohíbe la posibilidad de cobrar por el programa entregado, más allá de los costos de distribución física del mismo (soporte óptico o magnético, el precio del envío, cajas, ect.)

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el software libre y el gratuito (freeware). **La característica fundamental del software libre es la obligación de todos los desarrolladores de poner disponible el código fuente a cualquier usuario que así lo solicite,** de forma tal que estos últimos puedan realizar las modificaciones que estime conveniente y distribuirlas nuevamente.

De esta manera, el software libre se convierte en una creación colectiva, en la que, por lo menos en teoría, todos usuarios se encuentran en pie de igualdad al poder modificar el programa y adaptarlo a sus necesidades específicas.